

1501027-56.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... dos policiais, qualquer outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor do acusado Marcos.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1501027-56.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501027-56.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS LUIS LINDOSO BUENO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

MARCOS LUIS LINDOSO BUENO e JOEL ALVES DE ANDRADE, qualificado no autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 16 de abril de 2021, por volta das 00:20 horas, na Rodovia Pres. Dutra, BR 116, altura do KM 204, nesta cidade, agindo em concurso, traziam com eles para fins de tráfico 03 tijolos de maconha, contendo 1.515,49 g (massa líquida), 01 porção de maconha, com massa líquida de 99,78 gramas, 36 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 27,06 gramas e 50 comprimidos de LSD, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico, drogas essas que causam dependência física e psíquica.

Narra a acusação que policiais rodoviários federais abordaram o veículo Chevrolet Prisma Joy placa PZZ744, no qual estavam os acusados. O veículo foi abordado às 00:30 horas, na Rodovia Pres. Dutra, KM 204, sentido Rio de Janeiro. No interior do veículo foi localizado no assoalho do carro, próximo aos pés do réu Joel, uma sacola plástica que continha as drogas embaladas a vácuo. Com o acusado Joel foram localizados dois aparelhos celulares e com o acusado Marcos, que era quem dirigia o veículo, havia um celular e quantia em dinheiro. Indagados, o acusado Joel

confessou aos policiais que a droga lhe pertencia e que ele teria pagado R\$ 2.600,00 por ela, e que iria vender na cidade de Ilhabela, onde tem domicílio. Joel ainda teria dito que contratou por aplicativo o motorista Marcos, corréu, para fazer seu transporte de São Paulo a Ilhabela. Marcos, indagado, teria apresentado versão diferente, afirmando que nas imediações da rodoviária do Tietê foi contratado por Joel para viagem até São Sebastião. Os acusados foram presos em flagrante.

Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 01. Boletim de Ocorrência às fls.02/05. Auto de exibição e apreensão às fls.23/24. Laudo de constatação (fls.34/39

A decisão de fls. 70/76 converteu o flagrante em prisão preventiva ao acusado Joel e determinou a soltura do réu Marcos Luis, concedendo-lhe liberdade provisória.

Notificados, os réus apresentaram defesa preliminar às fls. 117 e 152.

A denúncia foi recebida em 20/08/2021, às fls. 174/175.

Laudo de exame toxicológico de fls. 220/224 e 247/249. Laudos periciais de objeto às fls. 241/246

Em audiência foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados (fls. 225/227 e 250/253).

O MP em alegações finais orais, pugnou pela procedência parcial da denúncia. Altercou inexistir dúvida de autoria do réu Joel, mas em relação ao acusado Marcos Luis não haveria provas suficientes de sua participação no delito. Quanto à dosimetria, altercou que Joel é reincidente em crime hediondo, o que deve constar em sentença. Afirmou que diante disso deve ser aumentada a pena em segunda etapa, como reincidência. Aduziu que na primeira etapa, as circunstâncias do art. 59 do CP são normais ao tipo, devendo ser observado o art. 42, da lei de Drogas, encontrados 4 tipos de entorpecentes com o acusado, demandando aumento pela quantidade e natureza dos entorpecentes, ficando a pena acima de 6 anos na primeira fase. Afirmou que a reincidência deve ser compensada com a confissão. Aduziu que não cabe a diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por razão da reincidência e das circunstâncias do delito. Requereu a fixação de regime inicial fechado.

Em alegações finais orais, a defesa do acusado Joel afirmou que o réu confessou os fatos, mas antes destes foi diagnosticado com câncer e precisava de dinheiro para se tratar. Afirmou que o acusado pode ser visto como “mula” do tráfico, sendo pessoa com baixo poder aquisitivo, aliciado para realizar o transporte por falta de oportunidades e diante de situação de pandemia. Pugnou pela pena no mínimo legal, reconhecendo-se a confissão do acusado. Aduziu que quer a compensação de reincidência com confissão. Ainda, requereu regime diverso do fechado, ao acusado, havendo circunstâncias judiciais favoráveis, tendo ainda passado por cirurgia há menos de um mês. Requereu a detração para aplicação do regime inicial de cumprimento. Requereu aplicação de medidas diversas da prisão, por estar ele preso há mais de um ano, havendo possibilidade de o réu apelar em liberdade.

Em alegações finais, a defesa do acusado Marcos requereu a absolvição do réu, conforme alegado pelo Ministério Público, não havendo provas de que o acusado sabia que o corréu trazia drogas consigo. Afirmou que o réu é pessoa com mais de 50 anos de idade, pai de família e trabalhador. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação de pena mínima, podendo ser aplicado o redutor do art. 33, §4º, do CP, com substituição por restritiva de direitos.

A decisão de fls. 254/255 manteve a prisão preventiva do acusado Joel, em 04/05/2022.

Os autos vieram conclusos para prolação de sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada conforme boletim de ocorrência, laudo de constatação e prova oral colhida.

A autoria de delito de tráfico de drogas pelo réu Joel restou comprovada. Contudo, no que se refere ao réu Marcos Luiz, inexistiu prova de autoria delitiva.

Passo à análise da prova oral colhida no feito:

A testemunha Fred Henrique dos Santos declarou que é policial rodoviário federal e na data dos fatos abordaram o veículo com os dois réus, e o passageiro trazia um pacote próximo ao banco de passageiro, no qual havia entorpecentes. Disse que havia maconha, Skank e LSD no pacote. Afirmou que na condução do veículo estava o réu Marcos e Joel era passageiro. A mochila estava próximo aos pés do passageiro, na parte da frente. Quando chegou já pôde ver o pacote, que era grande. Disse que perguntou ao passageiro o que tinha no pacote, e ele falou que era droga, e abrindo, constatou que realmente era droga. Narrou que o condutor do veículo viu depois a droga e ele e o acusado Joel deram versões contraditórias, o que está em seu depoimento em delegacia. Não se recorda se o corréu Marcos assumiu a droga. O pacote poderia parecer outra coisa, mas o cheiro de droga era perceptível.

A testemunha Erasto Brochieri Neto declarou que é policial rodoviário federal e que na data dos fatos abordaram o veículo em que estavam os réus, indo para o litoral. No carro havia uma caixa com maconha, cocaína e LSD. Disse que a caixa estava no chão, em frente ao passageiro. Disse que os réus aparentavam nervoso, e cada um deles contou uma versão da viagem que faziam. Disse que quando foi localizada a droga o réu Joel confessou que era dele a droga e estava levando para Ilhabela. O motorista disse que era uber e passava na rodoviária e via quem iria ao litoral. O passageiro disse que ligou para o rapaz e ele foi lá pega-lo, mostrando o celular com ligação. Cada um falou um valor diferente pela corrida. Narrou que em revista pessoal não havia nada de ilícito com o motorista e toda a droga estava na caixa aos pés do passageiro.

A testemunha Pedro Henrique Massareli declarou ser policial rodoviário federal e que não se recorda da ocorrência. Disse que não sabe se participou dessa ocorrência e não trabalhou com Erasto Brochieri e nem Fred Henrique. Afirmou que não conhece esses dois policiais. Acredita não ter feito parte dessa ocorrência, o que foi mencionado pelo MP ao final do depoimento.

O réu Marcos Luis Lindoso Bueno declarou em interrogatório judicial que tem 52 anos, é motorista profissional, trabalhando registrado desde julho do ano passado, trabalhou com taxi, com aplicativo e depois do que aconteceu teve crise de pânico, e agora conseguiu emprego registrado. Tem renda mensal de R\$ 1.341,00. Estudou até ensino médio completo. Tem filhos e netos. Está casado novamente. Afirmou que nunca teve problemas com a justiça e desde os 14 anos trabalha registrado. Disse que o policial falou que pegou uma caixa de um tamanho de 10 cm, que estava na mochila de Joel. Não conhecia Joel. Joel trazia com ele essa mochila. Afirmou que foi fazer viagem para São Paulo e trabalhava nessa época com aplicativo. Alugou um carro para trabalhar com aplicativo. Disse que veio para São Paulo para levar pessoas, passou na rodoviária do Tietê e perguntou se alguém queria vir para o litoral. Afirmou que sempre tem pessoas querendo vir para São José dos Campos, Ilhabela, Caraguatatuba. Fazia isso para compensar a vinda e ida para São Paulo. Joel aceitou e o pegou na rodoviária do Tietê. Afirmou que cobrou de Joel R\$ 300,00 e ele viria para Ilhabela, até a balsa. Afirmou que veio pela Dutra para passar por São José dos

campos, pois iria ver se mais pessoas queriam vir para o litoral. Afirmou que precisa trabalhar muito para suprir necessidades. Não sentiu cheiro de drogas, pois seu carro tem “cheirinho” e a mochila estava fechada. Quando o policial tirou a droga da mochila, esta estava numa caixinha de papelão embalada, como aquelas que enviam pelo correio. Afirmou que viu os policiais abrindo a caixa de dentro da mochila. Joel respondeu ao policial que era maconha que tinha na caixa. Disse que na delegacia colocaram 3 tijolos de maconha na mesa. Estava tudo dentro da caixinha. Afirmou que tinham 3 tabletes e outras coisas que não conhecem muito. A droga estava bem embalada na caixa com uns “negócios” brancos e não sentiu cheiro nem na delegacia. Narrou que tem 52 anos, nunca teve problemas com a justiça e veio para São Sebastião para criar seus filhos em local tranquilo, acontecendo isso com ele. Afirmou que quer viver em paz e teve crises de pânico após esses fatos. Sempre andou de cabeça erguida, trabalhou e sustentou seus filhos, não fazendo besteira agora com 52 anos de idade.

O acusado Joel Alves de Andrade declarou em interrogatório judicial que tem 49 anos, é pintor e tem firma de pintura. Tem renda mensal em média de R\$ 3.000,00 a R\$4.000,00. Não terminou o segundo grau. É solteira e tem duas filhas maiores e netos. Afirmou que já foi processado antes, sendo condenado pelo art. 214 do CP. Narrou, em relação aos fatos, que na pandemia ficou desempregado e fez besteira, reconhecendo isso. Tem diabetes e toma remédio, fazendo exames a cada 6 meses, descobrindo estar com câncer, sendo encaminhado a oncologia de São José dos Campos. Contou isso a um amigo que lhe perguntou se ele queria ganhar um dinheiro, que ele teria que buscar algo em São Paulo. Aceitou, ciente do que era. Chegando em São Paulo, foi até um local em que pegou um pacote fechado, sabendo que era “vácuo”, pois os policiais quando o prenderam falaram que estava tudo a vácuo. Afirmou que não podia mexer no pacote e estava tudo blindado num esparadrapo marrom, não saindo cheiro. Disse que os policiais afirmaram que a apreensão era boa. Iria ganhar R\$ 400,00 para levar essa droga, dizendo o policial que havia maconha, cocaína e Skank. Outro policial disse que tinha comprimidos de drogas. Afirmou que não usa drogas há 26 anos e não bebe, mas reconhece seu erro e praticou esse crime de transporte, mas não vive do tráfico. Narrou que se fosse preso na sua cidade seria escândalo, por ser crente. Narrou que precisa de uma oportunidade. Narrou que o corréu Marcos não conhecia, e o viu na rodoviária. Quando pegou a droga foi na rodoviária, pois iria dormir ali para pegar o primeiro ônibus do dia seguinte. O corréu trabalha com aplicativo de carona e passou pela rodoviária perguntando quem queria vir para Ilhabela, e aceitou. O corréu queria pegar mais clientes em São José dos Campos e por isso vieram pela Dutra e não pela outra rodovia Airton Senna, mais rápida. O policial quando abordaram perguntaram para onde iriam, respondeu Ilhabela e o corréu São José dos Campos. Afirmou que nada foi encontrado no carro, pois tudo estava na sua mochila, pois trazia consigo a droga. Não é traficante e assume o que fez. Foi operado do câncer e vai fazer quimio. Disse que somente pede uma chance para ressocializar e voltar à sua família. Se for condenado, queria sair, pois ali se sente negligenciado.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Pela prova colhida nos autos, não há certeza de que o réu Marcos Luis possuía drogas para fins de tráfico. Em relação ao corréu Joel, contudo, há prova suficiente para o édito condenatório.

Primeiramente, anoto que o laudo pericial acostado às fls. 220/224 e 241/246 confirmou a natureza entorpecente das drogas encontradas.

Em seu interrogatório, como se pode observar, o réu Marcos Luis negou a prática do delito de tráfico, alegando que trabalhava como motorista e como tinha vindo para a cidade de São Paulo e teria que retornar ao litoral. Afirmou que para ter maiores ganhos na viagem, passou pela rodoviária para verificar se alguma pessoa queria ir ao litoral, oferecendo transporte de pessoas a cidades como Caraguatatuba, Ilhabela

e São José dos Campos. Aduziu que o réu Joel contratou seu serviço de transporte na rodoviária do Tietê e que não sabia que ele trazia consigo drogas. Afirmou que não sentiu cheiro de entorpecentes e que estes estavam bem embalados, o que viu quando a polícia encontrou os entorpecentes. Sustentou que no caminho para o litoral iria parar em São José dos Campos para verificar se mais algum passageiro tinha interesse em ir para o litoral.

Os policiais narraram como abordaram os acusados na data dos fatos, indicando, um deles inclusive, o policial Erasto, que o réu Marcos falou que era motorista de uber e que teria pegado o réu Joel na rodoviária do Tietê. Afirmaram que a droga estava aos pés do réu Joel.

O réu Joel negou que Marcos traficasse drogas em conjunto com ele. Joel confessou que foi buscar drogas em São Paulo e levaria para Ilhabela, e que receberia um certo valor por tal serviço. Narrou, como todos os demais depoimentos, que as drogas estavam num pacote embrulhado e a vácuo, que estava aos seus pés, no banco de passageiros do veículo.

Em sede policial os acusados permaneceram em silêncio (fls. 21/22).

O Ministério Público em sede de alegações finais orais pugnou pela absolvição do réu Marcos Luis, por entender que inexistem provas suficientes para a condenação.

Com efeito, em relação ao réu Marcos Luis, efetivamente de relevante existe apenas o encontro de entorpecentes pelos policiais rodoviários federais no interior de veículo que ele dirigia, não havendo quaisquer outros indícios que apontem qualquer vinculação do réu Marcos com a droga ou mesmo ciência da sua existência..

Observo que a mera menção de que haveria cheiro de droga no veículo, exalando do pacote, não é passível de verificação concreta, e o acusado Marcos nega que a droga exalava cheiro. Como inclusive consta na peça acusatória, a droga estava embalada a vácuo, e o réu Joel afirmou que todo entorpecente estava embrulhado com esparadrapo marrom, não exalando cheiro.

O réu Joel foi firme ao afirmar que trazia sozinho as drogas, e que o réu Marcos apenas havia sido contratado por ele na rodoviária do Tietê, para ir a Ilhabela, pois não haveria mais ônibus naquele dia para tal cidade. Joel, em interrogatório, esclareceu, ainda, a alegada divergência que os policiais indicam nos depoimentos dos réus quando abordados na rodovia Dutra. Informou Joel que o corréu Marcos preferiu pegar a rodovia Pres. Dutra pois iria parar em São José dos Campos para ver se mais alguém tinha interesse em ir para o litoral. Assim, quando da parada da polícia, perguntados sobre o destino, Marcos teria dito São José dos Campos, que era a parada que iriam fazer, enquanto Joel teria dito Ilhabela, que era o ponto final de seu destino.

Vê-se que, de todo modo, pela prova colhida nos autos, não há certeza do envolvimento do réu Marcos Luis coma empreitada criminosa.

Cabe observar que o réu Marcos negou a propriedade da droga com veemência e o interrogatório do corréu Joel, como dito, aponta que o Marcos sequer sabia que havia drogas no veículo.

Ressalto ainda inexistir qualquer perícia grafotécnica que aponte que efetivamente Marcos teve qualquer contato com as drogas, não se confirmando digitais de referido acusado no pacote com entorpecentes.

Como sói ocorrer, não foi trazida qualquer outra testemunha, que estivesse presente no momento em que houve a aquisição de drogas pelo réu Joel, ou que comprovasse conluio dos acusados na mercancia e transporte de entorpecentes.

Forçoso, in casu, verificar que, tendo negado o réu Marcos a propriedade ou porte da droga em juízo, e não havendo, além da declaração dos policiais, qualquer outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor do acusado Marcos.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Mercancia não comprovada - Indícios insuficientes para formar convicção nesse sentido - Réu preso em companhia de menor reconhecido e indicado como traficante - Ausência de atos seguros e concretos vinculando suas ações - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido - (TJSP, APELAÇÃO Nº: 990.09.047397-5 - COMARCA: ITAPEKERICA DA SERRA APTE WELLINGTON DA SILVA SANTOS APDO : Ministério Público).

Frise-se, ainda, por oportuno, que sequer houve a vinda aos autos de perícia no celular dos acusados, com conversas entre eles apontando o tráfico conjunto de entorpecentes.

Assim, a despeito da probabilidade da ocorrência do tráfico de drogas e mesmo que se considere pouco crível a versão apresentada pelo réu Marcos, o conjunto probatório produzido não se mostra firme o bastante para lastrear uma condenação por tráfico de drogas pelo acusado.

Destarte, nesta fase processual, encerrada a instrução, se alguma dúvida existe deverá ser interpretada em favor do réu, conforme recomenda a boa técnica processual penal.

Como é cediço, em casos de dúvida, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição da acusada como medida de justiça. Sobre a presunção de inocência, manifesta-se Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2008, p.178/19):

"...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos."

Continua o jurista:

"Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo"

Assim, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade.

A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque:

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313

No mais, conforme leciona o Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 150), membro do Ministério Público de São Paulo:

“A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco – mínima que seja – de condenar quem nada deva.

Quando se tem presente, salientou Malatesta, que a condenação não pode basear-se senão na certeza da culpabilidade, logo se vê que a credibilidade razoável – também mínima – da inocência, sendo destrutiva da certeza da culpabilidade, deve, necessariamente, conduzir à absolvição”.

Com efeito, uma sentença judicial condenatória deve ser embasada em elementos objetivos, contundentes e sólidos. Em verdade, para fins de condenação criminal, a intuição deste julgador não tem qualquer importância. Não basta a crença, deve haver certeza.

Novamente, colaciona-se o escólio do Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 15):

A respeito, obtempera Heleno Cláudio Fragoso que “a condenação exige certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de nossa mente em torno da existência de certa realidade”. Mesmo a íntima convicção do Juiz – pondera Sabatini –, como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação (g.n.), não é verdadeira e própria certeza (...); no lugar da certeza, em espécie tal, tem-se a simples crença.

Em relação ao réu Joel, contudo, o entendimento é diverso, como já destacado.

Referido acusado, como dito, confessou o delito, afirmando que por necessidade financeira, por estar desempregado e adoentado, aceitou receber quantia em dinheiro para levar a droga de São Paulo para Ilhabela. Afirmou que sabia que havia droga no pacote que recebera em São Paulo e que agiu sozinho.

Como já mencionado, os policiais rodoviários federais e o corréu Marcos confirmaram que as drogas estavam sendo trazidas por Joel no interior do veículo que Marcos dirigia, estando embaladas a vácuo, com esparadrapo marrom, e colocada no assoalho do veículo.

Recorda-se, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das outras condutas descritas no

mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS É ILÍCITA, E DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL, POR NÃO TER CHEGADO AO DESTINO, QUE NÃO FORAM VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUTA DE TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER, AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 2. "Transportar", "trazer consigo" ou "fornecer ainda que gratuitamente" substância entorpecente ilícita são São Paulo núcleos do tipo do delito de tráfico de drogas - crime de perigo abstrato, de ação múltipla e conteúdo variado, que se consuma com a prática de quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei Antidrogas. (HC 225555/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 09/12/2012).

Conforme a folha de antecedentes de fls. 120/121, é inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por ser o réu Joel reincidente.

Inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente o réu Joel de pena.

No mais, a ação foi culpável, reprovável, pois o réu Joel era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado JOEL ALVES DE ANDRADE, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. ABSOLVO, todavia, o réu MARCOS LUIS LINDOSO BUENO, qualificado nos autos, de todas as imputações que lhe foram dirigidas, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena.

Assim, primeiramente, no tocante às circunstâncias judiciais, verifico que a ré agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. O réu não possui maus antecedentes, servindo a condenação anterior como reincidência (fls. 60/67). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias, todavia, se mostram desfavoráveis, já que a quantidade, a despeito de não ser imensa, é significativa, admitindo, por tanto, uma valoração negativa, considerando o teor do art. 42, da Lei 11.343/06.

Diante disso, imponho ao réu a pena-base de 06 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, no menor valor legal.

Incidirá a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Portanto, tenho por bem em compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, inclusive como requerido pelo Parquet, não havendo que se falar em circunstância preponderante.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria caso se trate de flagrante ilegalidade e não seja necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. Vale dizer, "o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 11/4/2005). III - Na espécie, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, independe se a confissão foi integral ou parcial, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação. Incidência da Súmula n. 545/STJ. IV - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." V - Na hipótese, não obstante seja o paciente reincidente específico, entendo que podem ser compensadas a agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea, mormente se considerada a ausência de qualquer ressalva no entendimento firmado por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo sobre o tema. VI - A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva foi fixada em 1/5 (um quinto) com base em elementos concretos e de acordo com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na majoração da reprimenda. VII - Ainda que estabelecida a pena-base no mínimo legal, sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. VIII - A eventual possibilidade de aplicação do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, sendo inviável sua análise neste Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, redimensionando a pena do paciente para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (HC 365.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 23/11/2017)

Portanto, mantenho a pena base fixada.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, à míngua de outras causas modificadoras, fica o réu JOEL ALVES DE ANDRADE definitivamente condenado pelo delito de tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos de reclusão cumulada com 500 dias-multa, no mínimo legal.

Do regime inicial de cumprimento de pena e alternativas penais:

Nos termos do quanto preconiza o art. 33, § 2º e alíneas e §3º, do Código Penal, e tratando-se de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

O réu Joel está preso desde 16/04/2021. Não obstante, deixo de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, uma vez que, mesmo computado o tempo em que o réu esteve preso provisoriamente, não haveria alteração do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez tratar-se de réu reincidente. Assim, a detração será realizada, no momento apropriado, pelo juízo da execução.

Inviável a substituição da pena privativa por restritiva de direito já que ausentes os requisitos legais do art. 44, do Código Penal.

O réu Joel respondeu preso ao processo. Assim, inalteradas as circunstâncias que levaram à sua segregação cautelar, nego ao réu o direito recorrer em liberdade., ficando, desta feita, mantida a prisão preventiva.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

- a) Lançamento do nome dos condenados no Rol dos Culpados.
- b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada aos sentenciados.
- c) Comunicação à Justiça Eleitoral que os sentenciados encontram-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.
- e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.
- f) Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial.
- g) Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, fica autorizada a alienação e destinação do produto ao Funad ou Funpen, conforme o caso, a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda, no caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, decreto a perda da integralidade do valor, tudo conforme disposto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ.

Cautelas e comunicações de estilo.

P.I.C.

Aruja, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA